



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 33907/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 02/02/2024

TRA

Parte_1 c.f. e P.IVA *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dario M. Tepedino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Napolitano, in Napoli alla Via Broggia n.3;

ATTRICE

E

Controparte_1, c.f. *C.F._1*, *Controparte_2*, c.f. *C.F._2*, *Controparte_3* c.f. *C.F._3* [...] *CP_4*, c.f. *C.F._4*, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Vincenzo Di Monte, Giampiero Di Lorenzo ed Emanuele Di Monte, elettivamente domiciliati presso la sede di Napoli dello studio *Organizzazione_1* in Galleria Umberto I n. 27;

- CONVENUTI

Controparte_5, c.f. *P.IVA_2*, in persona del curatore avv. *Persona_1*

- CONVENUTO CONTUMACE

CP_6 P.I. e c.f. *P.IVA_3* in persona del legale rappresentante p.t., e per essa, quale mandataria, *CP_7* rappresentata e difesa, dall'avv. Deosdedio Litterio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 67

- INTERVENUTA

Oggetto: Accertamento del credito ed azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* ha evocato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la società *CP_5* unitamente ad *Controparte_1*, *Controparte_2*, [...] *CP_3* e *CP_4* al fine di accertare il credito di complessivi euro 1.849.427,75 vantato nei confronti della società *CP_5* in qualità di debitrice principale, e di [...] *CP_1*, *Controparte_3* e *CP_4*, in qualità di fideiussori, a titolo di esposizione debitoria del rapporto di conto corrente ordinario n. 10556541 e del conto corrente n. 101366607 sul quale veniva regolato un finanziamento chirografario per l'originario importo di euro 250.000,00, sottoscritti dalla società *CP_5* con *Parte_1* [...] ha chiesto, altresì, di dichiarare l'inefficacia, e per l'effetto, revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di datio in solutum del 4 maggio 2017 per Notaio *Controparte_8* Repertorio n. 13.445 - Raccolta n. 6.330, con il quale *Controparte_1* cedeva alla madre *CP_2* [...] la nuda proprietà delle seguenti unità immobiliari site in Napoli alla via Giovanni Porzio, "Centro Direzionale", lotto "2/B", fabbricato "B":

-- appartamento ad uso ufficio al settimo piano catastale della scala "A", contraddistinto con il numero interno 24, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli in ditta *Controparte_2*, usufruttuaria, e *Controparte_1*, nudo proprietario, al fol. 9, particella 119, sub. 80, via Giovanni Porzio, piano 7, (erroneamente) int. 23, scala "A", z.c. ottava, Sez. VIC., cat. A/10, classe quinta, vani 5,5, superficie catastale totale 114 mq, rendita euro 2.797,91;

-- posto auto scoperto al piano interrato, contraddistinto con il numero 30, superficie catastale di circa 14 metri quadrati, riportato nel catasto fabbricati del Comune di Napoli al fol. 9, Sez. VIC., particella 119, sub. 143, via Giovanni Porzio n. 4, piano S/2, interno 30, edificio "A/7", z.c. ottava, cat. C/6, classe ottava, consistenza 14 mq., rendita euro 77,37.

Parte attrice fondava la propria pretesa creditoria sull'esposizione debitoria pari a complessivi euro 1.849.427,75 derivante per euro 1.792.025,50, oltre interessi per euro 454,33, dal rapporto di conto corrente ordinario n.10556541 e per euro 56.933,48, oltre interessi per euro 14,44, dal conto anticipi n.101366607 sottoscritti dalla società *CP_5* con *Parte_1*

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni della debitrice principale ^{Cont}, *Controparte_1*, *Controparte_3* e *CP_4* prestavano fideiussione omnibus con atti del 7/10/2009 sino alla concorrenza di euro 1.318.200,00, del 31/03/2011 a garanzia del rientro dell'apertura di credito

di euro 250.000,00, del 30/09/2011 sino alla concorrenza della somma di euro 2.145.000,00 e del 27/12/2011 sino alla concorrenza della somma di euro 2.535.000,00.

Si costituivano *Controparte_1* ed *Controparte_2*, i quali chiedevano il rigetto delle domande attoree eccependone l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, il comportamento in mala fede dell'istituto bancario e l'infondatezza della domanda di revocatoria.

Si costituivano anche la società *CP_5* e *CP_4* e *Controparte_3* i quali eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la mancata prova del credito vantato, la violazione dei principi di trasparenza e correttezza da parte della banca, la mancata indicazione dei tassi d'interesse applicati e l'applicazione di commissioni illegittime, nonché la mancata informativa nei confronti dei fideiussori.

Concludevano per il rigetto delle domande attoree ed a tal fine depositavano perizia contabile.

Con comparsa depositata in data 12/03/2020, interveniva nel giudizio *CP_6* e per essa, quale mandataria, *CP_7* in qualità di cessionaria del credito vantato da parte attrice nei confronti dei convenuti.

Ai fini della decisione, all'udienza del 22/09/2020, veniva nominato il dott. *Persona_2* quale CTU al fine di verificare e ricalcolare il rapporto dare avere tra le parti.

All'udienza del 20/05/2022 il GU, preso atto dell'intervenuto fallimento della convenuta [...] *CP_5* in virtù di sentenza del Tribunale di Napoli del 19/08/2021, dichiarava l'interruzione del giudizio, poi riassunto dalla *CP_6* con atto notificato il 26/07/2022.

Ritenuta matura la causa per la decisione, il GU, all'udienza del 02/02/2024, tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per assenza dei convenuti, come da verbale del 21/05/2019 allegato.

La domanda è fondata.

Parte convenuta non ha disconosciuto alcuno dei documenti depositati da parte attrice, né le sottoscrizioni in calce agli stessi, con conseguente non contestazione dell'esistenza dei rapporti contrattuali oggetto di causa e delle relative condizioni economiche che devono considerarsi provate anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.

Dai documenti prodotti dalla banca creditrice risulta l'attestazione di tutti i movimenti contabili relativi ai rapporti bancari intervenuti tra le parti e rappresentano il titolo della pretesa creditoria, incombendo, pertanto, sui debitori l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento del saldo debitorio.

Parte attrice, oltre al contratto di apertura di credito regolata su c/c n. 101366607 e conto corrente ordinario n.10556541, sottoscritti dalla CP_5 con la banca, nonché le fidejussioni sottoscritte da Controparte_1 , Controparte_3 e CP_4 in data 07/10/2009, 31/03/2011, 30/09/2011 e 27/12/2011, depositava gli estratti conto del rapporto n. 10556541 a decorrere dal 01/12/2005, data di accensione del conto, sino all'estinzione dello stesso datata 31/03/2016, unitamente agli estratti di conto corrente del rapporto bancario n.101366607, a decorrere dall'accensione in data 04/04/2011 sino all'estinzione del 31/03/2016.

In ordine al debito derivante dai suddetti rapporti, peraltro riconosciuto dalla stessa società debitrice in occasione dell'accettazione del piano di rientro del debito maturato al 17/04/2015, del 05/04/2016 e della proposta di pagamento a saldo e stralcio del 10/01/2018 (doc. 7, 9 e 10 attrice), il nominato CTU, nel proprio elaborato, oggetto anche delle deduzioni dei consulenti di parte ed alle cui conclusioni questo giudice ritiene di prestare integrale adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, ha provveduto a rideterminare i saldi dei rapporti bancari, ad eccezione del conto anticipi n.101366607 per il quale non si è resa necessaria alcuna rielaborazione atteso che, come ampiamente chiarito in relazione, *“trattasi di rapporto acceso ed utilizzato esclusivamente per la gestione della linea affidativa di euro 250.000,00 le cui condizioni economiche risultano validamente pattuite all'atto della sottoscrizione della scheda negoziale del 31.03.2011”*, alla data del 31/03/2016 - data di passaggio a sofferenza del saldo debitore dei conti oggetto di causa - e non alla data della domanda (18/10/2018), stante l'assenza di documentazione contabile per il periodo intercorrente tra il 31/03/2016 ed il 18/10/2018.

Il consulente nominato, nell'espletamento dell'incarico, ha accertato che le condizioni economiche del rapporto di conto corrente risultano regolarmente convenute tra le parti esclusivamente a far data dal 07/10/2009, che le commissioni di massimo scoperto addebitate nell'ambito del c/c n.10556541 non risultano regolarmente convenute tra le parti e che gli oneri equipollenti alle CMS risultano validamente pattuiti all'atto della concessione degli affidamenti.

Dalle verifiche effettuate risultano, invece, validamente convenute tra le parti le condizioni del contratto di finanziamento.

Dall'esame della documentazione il CTU ha rilevato, altresì, che alla data di estinzione del rapporto di conto corrente n.10556541, la banca indicava una sofferenza di euro 1.983.103,64, mentre nell'atto introduttivo del presente giudizio Parte_1 si dichiarava creditrice del minore importo di euro 1.792.025,50 oltre interessi.

Ne deriva, quindi, che *“nel periodo ricompreso tra la chiusura dei rapporti (31.03.2016) e l'avvio del procedimento giudiziario (18.10.2018) – arco temporale non coperto da alcuna documentazione di natura contabile – la società correntista ha operato pagamenti – in favore di Parte_1 –*

quantomeno per euro 191.078,14. Di tanto, difatti, si riduce l'esposizione debitoria del c/c ordinario n.10556541 (euro 1.983.103,64 – euro 1.792.025,50)".

Sulla scorta di tali assunti, le indagini peritali hanno permesso di rideterminare il debito della [...] CP_5 in euro 1.737.569,05 per il rapporto di conto corrente n.10556541, a fronte di euro 1.792.025,50 richiesti dalla banca, ed euro 56.670,48 per il rapporto n.101366607, a fronte di euro 56.933,48 richiesti e da cui il consulente d'ufficio, pur non avendo proceduto al ricalcolo, ha detratto l'importo di euro 263,24 *"presumibilmente riferito ad interessi maturati successivamente alla chiusura del conto corrente, interessi per i quali in atti non vi è alcuna documentazione contabile"*.

Pertanto, nonostante la perizia della società convenuta indicasse il saldo debitore in euro 68.782,12 (doc. 12 convenuta), il credito di parte attrice è pari ad un totale di euro 1.794.239,53.

Accertato il credito azionato nei termini indicati, occorre esaminare le doglianze di parte convenuta relative alle fideiussioni prestate.

A tal riguardo va premesso che, nel caso in esame, diversamente da quanto affermato dalla creditrice, non è configurabile un contratto autonomo di garanzia.

Difatti, la giurisprudenza predominante ritiene, condivisibilmente, che l'inserimento nel contratto della clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" sia un chiaro indice sintomatico della volontà delle parti di rendere del tutto autonomo il contratto di garanzia dal rapporto principale.

Nel caso de quo, tuttavia, negli atti di fideiussione oggetto di causa è inserita solo la clausola di pagamento a prima richiesta, mentre non vi è alcuna esplicita rinuncia dei garanti alla proposizione delle eccezioni. Questa circostanza è certamente rilevante al fine di escludere la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia.

La banca, infatti, quale operatore qualificato che ha predisposto il modulo contrattuale, se avesse voluto concludere un contratto autonomo avrebbe dovuto includere nel contratto la clausola di rinuncia alle eccezioni; tale omissione, dunque, rende chiara la volontà della banca di non rendere del tutto autonoma la garanzia dal rapporto principale. Questo elemento, pur rilevante, non è sufficiente da solo per qualificare il rapporto negoziale in quanto, in un caso simile, la Cassazione ha precisato che l'inserimento nel contratto della sola clausola di "pagamento a prima richiesta" (priva dell'esplicita rinuncia alla proposizione delle eccezioni) non ha rilievo decisivo per la qualificazione del negozio, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito che a fideiussioni (Cass. 9.8.2016 n. 16825). Oltre all'elemento sopra indicato vi sono, però, almeno altri due elementi decisivi che fanno propendere per la natura fideiussoria del negozio in esame.

In primo luogo, va sottolineato il dato letterale dei documenti, nei quali si fa a più riprese espresso riferimento al “fideiussore”, in tal modo richiamando in maniera esplicita la garanzia tipica del codice civile.

Ciò risulta ancor più significativo se si tiene conto del fatto che il modulo è stato predisposto dalla banca la quale, si ripete, come operatore professionale qualificato, non poteva ignorare il significato giuridico dei termini adoperati.

Dunque, appare evidente che se la banca avesse voluto far sottoscrivere ai convenuti un contratto autonomo non li avrebbe definiti 'fideiussori' bensì 'garanti'.

Inoltre, il regolamento contrattuale fa espressamente rinvio alle disposizioni codicistiche in tema di fideiussione, sia pure per derogarvi parzialmente. Ad esempio, nel contratto di garanzia in oggetto si individua la deroga espressa a quanto previsto dall'art. 1957 c.c.

Risulta chiaro che la banca, che ha predisposto il testo contrattuale, ha dovuto prevedere una deroga espressa alla disciplina codicistica della fideiussione, testualmente richiamata, proprio sul presupposto che la garanzia stipulata fosse riconducibile a questo schema contrattuale.

Posta, quindi, la natura non autonoma della garanzia in esame, ne discende che i convenuti siano legittimati a sollevare le medesime eccezioni della debitrice principale.

Nel caso di specie parte convenuta chiedeva accertarsi la nullità assoluta della fideiussione prestata.

Sul punto, di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto “*I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti*” (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994).

La Corte di Cassazione, con la pronuncia citata, una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, ha affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di "conservazione" del negozio. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli

articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Org_2 n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.

La Suprema Corte ha, poi, affermato che la violazione della normativa antitrust deriva dal "collegamento funzionale" e non certo "negoziale" fra gli atti, attesa la possibilità che l'"intesa" a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed Eurocomunitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti "funzionale" a produrre un effetto anticoncorrenziale. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. È, invece, il predetto "nesso funzionale" tra l'"intesa" a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame, emerge che i convenuti abbiano prestato fideiussione omnibus in data 07/10/2009, 30/09/2011, 31/03/2011 e 27/12/2011 a garanzia dei rapporti obbligatori facenti capo alla CP_5 (doc. 12 attrice).

Acclarata la qualità di garanti in capo agli odierni convenuti, in ordine all'eccezione di nullità della fideiussione omnibus prestate dagli stessi va premesso che tale nullità non è ravvisabile nel caso di specie.

Difatti, l'art. 5 (art. 6 nel contratto di fideiussione del 31/03/2011) delle fideiussioni sottoscritte da Controparte_1, Controparte_3 e CP_4 prevede espressamente che *"I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita"*.

Poiché, contrariamente a quanto dedotto dagli odierni convenuti, la garanzia in oggetto “*non ricalca lo schema di fideiussione omnibus sottoposto al vaglio della Org_2 e dichiarato parzialmente invalido per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 in caso di sua applicazione uniforme con il provvedimento della Org_2 n 55/2005, essendo stata prevista la deroga all'art. 1957 c.c. non in toto, ma con la previsione del diverso termine di 36 mesi entro cui il creditore deve promuovere le sue istanze nei confronti del debitore ai fini di cui all'art. 1957 c.c. e non essendo le condizioni generali di contratto articolate secondo lo schema predisposto dall'ABI, anche in relazione alla successione delle clausole*” (cfr. Tribunale Roma, 24/02/2023, n.3162), la stessa non è affetta da nullità per violazione della normativa antitrust.

Considerato, quindi, che “*nel caso concreto la clausola in questione non rimuove tout court il termine semestrale di decadenza, ex art.1957 cc, senza apporre alcun altro, in linea con lo schema contrattuale ABI censurato dalla Org_2 , ma, appunto -in ciò discostandosi dallo schema ABI -prevede pur sempre un termine negoziale di decadenza (tre anni), più ampio di quello legale (sei mesi), con un limite temporale non irragionevolmente eccessivo, e di estensione tale da escludere che la stessa possa avere "lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca" (punto IX.96 del provvedimento n.55/2005 della Org_2)*” (così Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 02/01/2023, n.17) risulta priva di fondamento l'eccezione formulata da parte convenuta.

In ordine, poi, alla lamentata mala fede e responsabilità precontrattuale della banca, che parte convenuta indica quale causa di nullità delle obbligazioni assunte dai fideiussori, va detto che non vi è prova della mancata o negligente verifica da parte dell'attrice del merito creditizio della [...]

CP_5

Difatti, i convenuti, formulando contestazioni meramente generiche non hanno assolto all'onere probatorio gravante sugli stessi in merito all'inadempimento della creditrice.

Invero, proprio dai bilanci allegati da parte convenuta (doc. 3.1, 3.2, 3.3., 3.4 convenuta) emerge una situazione contabile della società CP_5 per la quale non vi erano motivi ostativi alla concessione del finanziamento rilevabili dall'istituto di credito.

Pertanto, va rilevato che, contrariamente alle deduzioni dei convenuti, i garanti non potevano non essere a conoscenza della situazione contabile della società, sia in quanto facenti parte della compagine sociale, sia perché a tanto tenuti dalle condizioni pattuite nei contratti di fideiussione.

Venendo all'esame della domanda di revocatoria, giova in termini generali rilevare che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, come è noto: a) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente; b) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento

da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'*eventus damni* anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore; c) nella ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

D'altronde, il pregiudizio (*eventus damni*), al quale fa riferimento l'art. 2901 c.c., va oltre il concetto di danno, per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 02.04.2004, n. 6511; Cass. 15.06.1995, n. 6777).

La Suprema Corte ha evidenziato invero che interesse del creditore non è soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento della revocatoria, sicché il pregiudizio (*eventus damni*) può essere costituito finanche da una variazione (sia quantitativa, che qualitativa) del patrimonio del debitore, purché tale variazione comporti appunto una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito, oppure ne comprometta la fruttuosità (Cfr. Cass. Civ. 04.07.2006, n. 15265; Cass. Civ. 29.10.1999, n. 12144; Cass. Civ. 08.07.1998, n. 6676; Cass. Civ. 06.05.1998, n. 4578).

Nella specie, con riguardo all'atto di disposizione oggetto di revocatoria, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.

Al fine di inquadrare correttamente la controversia occorre premettere che l'atto posto in essere da *Controparte_1* ed *Controparte_2*, con il quale *CP_1* estingueva il debito nei confronti della madre, originante dalla dazione a titolo di mutuo della somma di euro 145.000,00 a mezzo assegno n. 0019340870 del 12 settembre 2008, mediante la cessione della nuda proprietà degli immobili in Napoli sopra descritti con imputazione del prezzo a compensazione del debito scaduto, è riconducibile alla figura della *datio in solutum*.

Contrariamente a quanto dedotto dai convenuti, occorre fare applicazione del principio “*secondo cui la regola della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissata dall'art. 2901 c.c., comma 3, trova applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico, e non con riguardo a negozi riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto in senso proprio, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (Cass. 10 dicembre 2008, n. 28981, con riguardo alla cessione pro solvendo di tutti i crediti presenti e futuri vantati, fino ad un determinato importo, dal debitore verso un terzo): onde, se*

l'estinzione del debito avviene attraverso una datio in solutum, si verifica una scelta volitiva, da parte del debitore in accordo con il creditore, sufficiente ad escludere il carattere di "atto dovuto" dal meccanismo negoziale prescelto (cfr. Cass. 17 maggio 2010, n. 12045, in motivazione)" (Cassazione civile sez. VI - 14/11/2017, n. 26927).

Quindi, poiché si ricade in un'ipotesi di datio in solutum che costituisce una modalità di estinzione dell'obbligazione e che rappresenta l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, l'atto è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria (in tal senso Cassazione civile sez. II - 14/05/2024, n. 13227).

In ordine al requisito del credito a tutela del quale è stato introdotto il giudizio, risulta documentalmente provato che **Controparte_1** si costituiva fideiussore di **CP_5** per l'adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, che la medesima società avrebbe contratto con

Parte_1

Trattandosi di credito di cui si chiede l'accertamento nel presente giudizio, non rileva che si tratti di credito litigioso, ovvero *sub iudice*, in quanto non ancora oggetto di accertamento definitivo in sede giudiziale.

Sul punto, giova osservare che *“l'ammissibilità dell'azione revocatoria anche rispetto ad un credito sub iudice o eventuale ed è del tutto consolidato l'orientamento che esclude che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, sì da escludere la necessità della sospensione obbligatoria del primo processo in relazione al secondo. In tal senso è stato ritenuto che poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. testualmente, Cass., 3, 17/12/2013, n. 28155; Cass. 3, 14/5/2013 n. 11573; Cass., 1 12/7/2013 n. 17257; Cass. 3, 10/2/2016 n. 2673; Cass. Sez. 3, 12/02/2020, n. 3375) (Cassazione civile, 28/08/2023, n.25331).*

Ricorre, poi, il requisito del danno arrecato dall'atto di disposizione, oggetto di lite, alle ragioni di credito dell'attrice.

In proposito, va ribadito che il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. può essere costituito anche da un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, *ex multis*, Cass. civ. sentenza n. 15310 del 7 luglio 2007).

Nel caso di specie, la prova del requisito di cui si discorre emerge chiaramente dalla considerazione secondo cui, con l'atto per cui è causa, il fideiussore convenuto, sul quale incombeva l'onere di fornire la prova della titolarità di beni ulteriori in grado di assicurare il soddisfacimento delle ragioni della creditrice, si è reso impossibile.

Al riguardo, pur essendo stata provata la proprietà in capo a Controparte_1 di due immobili di modestissimo valore, tuttavia, non è stata dimostrata l'eventuale capienza del patrimonio di questi rispetto al credito dedotto da parte attrice.

“In proposito, va posto in risalto che il requisito oggettivo dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (v., tra le tante, Cass. n. 20232/2023; Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 1896/2012)” (Cassazione civile sez. II - 14/05/2024, n. 13227).

Relativamente al requisito soggettivo, poi, va rilevato che, nella specie, l'atto dispositivo posto in essere sia successivo al sorgere del credito.

Difatti, l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione è palese se solo si consideri che, come osservato, le garanzie prestate dal convenuto risalgono al 2009 e 2011 laddove, invece, l'atto oggetto di revocatoria è di maggio 2017.

Invero, *“In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato; infatti, l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali”* (cfr. Cass. 1413/2006)” (Cassazione, 18/04/2019, n.10824).

Ciò posto, occorre evidenziare che, siccome nella specie viene in rilievo un atto di disposizione successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è che il

debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo (cfr. *ex multis*, Cass. civ. n. 17327/11, 7452/00, 1280/03, 15389/05).

In particolare si afferma che, condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (c.d. *scientia damni*), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza (c.d. *scientia fraudis*), cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo (c.d. *consilium fraudis*) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. *animus nocendi*), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.

La sussistenza degli elementi psicologici richiamati della *scientia damni* e del *consilium fraudis* vanno provati dalla parte processuale che li allega e possono essere accertati dal giudice anche attraverso il ricorso a presunzioni, quali la divergenza tra prezzo di mercato del bene oggetto della cessione e prezzo pattuito o il mancato versamento del prezzo dichiarato nell'atto di compravendita intercorso (cfr. Cass. 21/9/2001 n. 11916, 13404/08), il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (v. *ex multis* Cass. n. 27546 del 2014; n. 17327 del 2011).

Come chiarito dalla Suprema Corte *"l'azione revocatoria ordinaria presuppone per la sua esperibilità la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, sicché, prestata fideiussione a garanzia delle future obbligazioni del debitore principale nei confronti di un istituto di credito, gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento di denaro da parte della banca, senza che rilevi la successiva esigibilità del debito restitutorio o il recesso dal contratto (cfr. Cass. 762/2016)"* (Cassazione n.10824 del 18/04/2019).

Ciò in quanto *"l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito"* (Cassazione, 10/01/2023, n.330), e la verifica dell'*eventus damni* deve essere compiuta con

riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito (cfr. Cass. Civ. n. 22465/06).

Tanto precisato, deve rilevarsi che, rispetto all'atto a titolo oneroso posto in essere dai convenuti, sia necessario, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo di cui all'art. 2901 c.c., la prova della consapevolezza da parte dei medesimi di arrecare pregiudizio alla creditrice.

Nella fattispecie, alcun dubbio può residuare ove si consideri che il fideiussore convenuto, unitamente agli altri garanti, riceveva raccomandata del 01/03/2016 con la quale la banca attrice comunicava la revoca degli affidamenti in conto corrente e conto anticipi concessi alla società garantita, nonché il recesso dal contratto di finanziamento e relativa costituzione in mora (doc. 8 attrice).

Inoltre, CP_1 era socio oltre che garante della CP_5 per cui era certamente a conoscenza della situazione finanziaria in cui versava la debitrice principale, e, conseguentemente, del pregiudizio che le ragioni creditorie avrebbero subito a cagione della diminuzione della garanzia creditoria.

Deve ancora evidenziarsi che, trattandosi di atto a titolo oneroso, ai fini in esame, deve sussistere, oltre alla consapevolezza del cedente, anche quella del terzo.

Considerato che *“necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”* (Cass. civ., 05/03/2009, n. 5359), nell'ipotesi in esame la prova della sussistenza del requisito soggettivo in capo alla CP_2, può desumersi dai rapporti familiari sussistenti tra la stessa ed il figlio Controparte_1, rammentando che la Suprema Corte *“ha più volte affermato la rilevanza indiziaria, anche ai fini della più pregnante prova della scientia o participatio fraudis, delle qualità soggettive delle parti (Cass. n. 13404 del 2008) e, segnatamente, del rapporto di parentela (Cass. n. 4175 del 2020; n. 12836 del 2014)”* (Cassazione civile sez. III - 23/02/2023, n. 5649).

Invero, nonostante la convenuta deduca a giustificazione della richiesta di restituzione della somma prestata le precarie condizioni economiche in cui la stessa versava, le allegazioni di parte attrice smentiscono tale assunto dando prova della consistenza immobiliare di cui era titolare [...] CP_2 (doc. 10 attrice).

Inoltre, non assume valenza l'argomentazione difensiva della convenuta relativa all'esigenza di ricostituire l'asse ereditario, anche su istanza delle figlie, posto che tale circostanza avvalorava il fatto

che i convenuti erano a conoscenza dell'esposizione debitoria della CP_5 e pienamente consapevoli dell'aggregabilità del bene da parte della creditrice.

E proprio la tempistica della richiesta di restituzione della somma mutuata, avvenuta a distanza di ben otto anni dal contratto di mutuo verbale e datata 18/05/2016, e, quindi, di poco successiva alla comunicazione del 01/03/2016 inviata da Parte_1 ai fideiussori, è indice del fatto che le parti dell'atto dispositivo abbiano posto in essere un'operazione fraudolenta ai danni della banca.

Infatti, le parti convenivano la restituzione della somma mutuata solo a seguito dell'insolvenza dell'odierna fallita e non finché la società debitrice era in bonis.

Deve ritenersi provato, quindi, che le parti contraenti fossero a conoscenza che l'atto dispositivo stipulato in quel contesto temporale avrebbe potuto recare pregiudizio alle ragioni dell'attrice.

Pertanto, sussistendone tutti i presupposti, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di trasferimento stipulato in data 04/05/2017 per notaio CP_8 Repertorio n. 13.445 Raccolta n. 6.330.

Quanto alla posizione dell'interveniente, deve osservarsi che risulta provata l'avvenuta successione nel credito oggetto di causa, in quanto la CP_6 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario, in virtù di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, del 19/9/2019, dalla Parte_1 alla CP_6 tra cui anche quello vantato dalla cedente nei confronti dell'obbligata principale CP_5 e dei garanti convenuti, e prova la titolarità del credito con il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 161 del 20/02/2020 (doc. 2 intervenuta).

Sul punto, pur dichiarando l'ammissibilità dell'intervento della CP_6 che conferiva procura speciale alla CP_7 con atto del 11 gennaio 2019 del Notaio Persona_3 di Milano, rep. 42728 - racc. 13238, per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti in sua titolarità, deve farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c.

Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, (Cassazione civile sez. I, 22/10/2009, n.22424) *“La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti”*(cfr. anche Tribunale Bari sez. I, 12/05/2015, n.2171).

Nel caso di specie è mancata l'autorizzazione di tutte le parti (compresa la cedente) all'estromissione di Parte_1 dal giudizio, conseguendone che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del

giudizio.

Da rigettare è, infine, l'eccezione relativa alla asserita mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB della **CP_7** **Parte_2** della **CP_6** in virtù di procura che versa in atti (doc. 3 intervenuta).

A tal riguardo la Suprema Corte è intervenuta con la recentissima pronuncia n. 7243 del 18 marzo 2024 ove rileva che le norme di settore, quali TUF e TUB, *“non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla **Org_2**) e presidiati anche da norme penali; – conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata””* per cui *“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”* (cfr. Cass. ord. n. 7243 del 18 marzo 2024).

Pertanto, l'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB dello special servicer, quale soggetto concretamente incaricato alla riscossione dei crediti cartolarizzati, non determina alcuna invalidità del mandato conferito.

Deve, infine, dichiararsi l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del fallimento **Cont**. Com'è noto, ai sensi della L. Fall., art. 52, la dichiarazione di fallimento del debitore, aprendo il concorso sul patrimonio del fallito, preclude la proposizione o la prosecuzione di azioni individuali da parte dei creditori, i cui crediti debbono essere accertati e soddisfatti nelle forme di cui agli artt. 92 e ss. della medesima legge, dinanzi al giudice delegato ed al tribunale fallimentare, la cui competenza attrae tutte le controversie che trovano la loro ragione diretta o indiretta e la loro origine ontologica e funzionale nel fallimento.

Ciò in applicazione del principio, assolutamente pacifico in giurisprudenza, secondo cui: *“Dichiarato il fallimento, ogni diritto di credito, ivi compresi i crediti prededucibili, è tutelabile nelle sole forme di cui agli artt. 92 ss. legge fall.; la previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito*

funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori, il che determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie" (Cass. 2002 n. 1065 e 2003 n. 515).

La *ratio* di tale orientamento è chiara: una volta che viene dichiarato il fallimento per poter assicurare che sia realizzato il principio della *par condicio creditorum*, occorre che le domande tese all'accertamento dei crediti, e dell'eventuale prededucibilità degli stessi, siano tutte proposte in sede concorsuale, poiché è solo in questa sede che la speciale procedura prevista dalla legge fallimentare consente che si possa effettivamente realizzare il principio della *par condicio creditorum*.

Accolta la domanda ex art. 2901 c.c., va poi ordinato al Competente Conservatore di Napoli di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità.

Rileva, da ultimo, il Tribunale che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, debbano seguire la soccombenza dei convenuti.

Si compensano nei rapporti tra cessionaria intervenuta e convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la contumacia del Controparte_5 ;
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna i convenuti Controparte_1 , [...] CP_3 e CP_4 , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 1.794.239,53 oltre interessi legali sulla sorta capitale dalla domanda al saldo;
- dichiara l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del fallimento CP_5 [...] ;
- accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto di trasferimento, stipulato in data 04/05/2017 per notaio CP_8 Repertorio n. 13.445 - Raccolta n. 6.330;
- ordina al competente Conservatore di Napoli di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite che si liquidano in euro 18.977 per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;

- compensa le spese di lite tra **CP_6** ed i convenuti.

Napoli, il 22/05/2024

Il giudice

Dott.ssa Fabiana Uchiello